

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2546 นาย สมศักดิ์ พณิชยกุล กับพวก จำเลย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 15, มาตรา 17

คำว่า **TWOWAY** เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทาง ซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า **TWOWAY** และทูเวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้

โจทย์ข้อจตทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัว
 กันTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัวWAYอันเป็นการผสมคำกับรูป
 ลูกศรซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่โจทก์กลับใช้
 เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์
 เช่น TellmeTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYPOWDERCAKEหรือTellmeCreance2รูป
 ลูกศรสลับหัวWAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme
 ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง การที่ ป. ใช้คำว่า
 "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้TWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัว WAY ไป
 ประกอบคำว่า sunmelonเป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิด
 เดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตก
 ต่างกัน และจะถือว่า ป. มีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค"ประกอบคำว่าซัน

เมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผิด
หน้าไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7
เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE เพื่อใช้กับสินค้า
แป้งแข็งของโจทก์ซึ่งผ่านการทดลองว่าสามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้ โจทก์
ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่วันที่ 2535 ตามคำขอเลข
ที่ 235556 ทะเบียนเลขที่ ค.11378 โจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษร
โรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY, TWO WAY ทู เวย์, 2 WAY ทู เวย์, ทู เวย์, 2
WAY POWDERCAKE และ Tellme Creance 2 WAY ไว้แล้วอีกด้วย เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2540 นางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า sun melon กับคำว่า "ชั้นเมลอน ทูเวย์เคค" ต่อกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 (ใหม่) รายการ
สินค้าแป้งผิดหน้าตามคำขอเลขที่ 347866 โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของ
นางสาวประกายคำมีคำว่า "ทูเวย์เคค" รวมกับคำ ชั้นเมลอน ซึ่งคำว่า "ทูเวย์เคค" มา
จากอักษรโรมันคำว่า TWO WAY CAKE มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียน
ไว้แล้ว หากนางสาวประกายคำนำเอาคำดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิด
เดียวกันกับของโจทก์แล้วจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ
หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ไม่ควรที่จำเลยที่ 1 จะสั่งให้นางสาวประกายคำไม่ขอ

ถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ ซึ่งนางสาวประกายคำก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัย 62/2542 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่นางสาวประกายคำต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยทั้งเจ็ดและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยที่ 984/2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดเป็นคดีนี้ ทั้งนี้โจทก์เห็นว่าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE มีเสียงเรียกขานว่า ทูเวย์ เพาเดอร์เค้ก โดยมีคำว่า TWO WAY เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY และอักษรไทยคำว่าทูเวย์ ที่ใช้กับสินค้าแป้งแข็งและได้ทำการทดลองมาเป็นเวลาหลายปีจึงพบว่าเนื้อแป้งสูตรใหม่นี้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเป็นพิเศษ คือ สามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้ โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จนเป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่สาธารณชน การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปใช้กับคำว่า sun melon ซึ่งมีเสียงเรียกขานว่าซันเมลอน และการที่นางสาวประกายคำใช้ภาษาไทยคำว่า ซันเมลอนร่วมกับการใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ตามมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ทั้งนี้ เพราะแม้จะมีการสละสิทธิแล้วคำดังกล่าวยังปรากฏในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำอยู่ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งเจ็ดมีคำวินิจฉัยว่า รูปลวดลายอยู่ในสี่เหลี่ยมและคำว่า sun melon กับคำว่า "ซันเมลอนทูเวย์เคค" กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้คือคำว่า TWO WAYPOWDERCAKE อักษร R ในวงกลมและรูปลูกศรประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำที่ใช้คำว่า ทูเวย์ แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกันกับอักษรโรมันคำว่า TWO WAY ซึ่งเป็น

สาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีอักษรโรมันคำว่า sun melon อักษรไทยคำว่า"ชั้นเมลอนทูเวย์เคค" และรูปลวดลายประดิษฐ์มีลักษณะเป็นลายเส้นอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบอยู่ด้วย โดยนางสาวประกายคำได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องหมายและมีอักษรโรมันคำว่า POWDERCAKE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงต่างกันนั้นเป็นการไม่ชอบ โดยโจทก์เห็นว่าการที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปรวมกับอักษรไทยคำว่า ชั้นเมลอน เพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยอาศัยความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าของนางสาวประกายคำ เพราะอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" เป็นคำที่มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY และ ทู เวย์ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า TWO WAY จะมีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY ก็ตามแต่สาธารณชนทั่วไปจะเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า TWO WAY หรือ ทูเวย์ อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ของนางสาวประกายคำจึงเป็นคำที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตามมาตรา 6 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 จำเลยที่ 1 น่าจะสั่งให้นางสาวประกายคำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเสียใหม่ โดยตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนาย

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 62/2542 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าที่ 984/2543 กับขอให้บังคับนางสาวประกายคำแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 3467866
เสียใหม่ โดยให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้แสดงปฏิเสธร
อย่างอื่นตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534

จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า การที่นางสาวประกายคำ ศรีวิชัยยอมสละสิทธิภาคส่วน
คำว่า ทูเวย์ ในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำดังกล่าวตามคำสั่งของ
จำเลยที่ 1 ก็เพราะว่า TWO WAY เป็นคำสามัญที่ใช้ในทางการค้าอยู่แล้ว โจทก์จะ
อ้างการถือสิทธิคำว่า TWO WAY แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ สาธารณชนไม่สับสนหรือ
หลงผิดเพราะเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำเห็นเด่นชัด การพิจารณาของ
จำเลยที่ 1 หรือคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ตามเหตุผลที่ปรากฏในคำวินิจฉัยที่
62/2542 หรือที่ 984/2543 จึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันชั้นนี้รับฟังได้ว่าโจทก์จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY
POWDERCAKE, TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY, TWO
รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ทูเวย์, ทู เวย์, 2 รูปลูกศร
สลับหัว WAY POWDERCAKE, (รูปภาพ) (Tellmme Creance 2 way) ตาม
เอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 และโจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO

รูปลูกศรกลับหัว WAY ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเอกสารหมายเลข 12 ด้วย ต่อมานางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า (รูปเครื่องหมาย) SUN MELON ชันเมลอนทุเวียเคคตามเอกสารหมายเลข 13 โจทก์ ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าโจทก์จดทะเบียนเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แล้ว การที่นางสาวประกาย คำยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับรายการสินค้าแป้ง ผัด หน้าจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ตัดคำว่า "ทุเวียเคค" ออกจากคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัย รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปผลดลยและคำว่า sun melon กับ คำว่า "ชัน เมลอนทุเวียเคค" ของนางสาวประกายคำ ตามเอกสารหมายเลข 16 โจทก์อุทธรณ์คำ วินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แต่คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ ตามเอกสารหมายเลข 18

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่า โจทก์จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE แม้จะมีการสละไม่ถือสิทธิ ในถ้อยคำว่า "POWDERCAKE" และตัว R แต่ก็ยังมีเครื่องหมายการค้า TWO รูป ลูกศรกลับหัว WAY และ 2 รูปลูกศรกลับหัว WAY ซึ่งมีเสียงเรียกขานได้ว่า "ทุเวีย" โดยสละไม่ขอถือสิทธิในคำว่า "ทุ" แต่การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทุเวียเคค" ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับคำว่า sun melon และคำว่า "ชันเมลอน" เป็นการไม่สุจริตและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คณะ กรรมการเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคำสั่งให้ตัดอักษรไทยคำว่า "ทุเวียเคค" ออกเสีย หรือมีคำสั่งให้นางสาวประกายคำแสดงปฏิสระอย่างอื่นตามนัยมาตรา 15 หรือมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ เห็นว่า คำว่า TWO WAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทางซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อม สามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWO WAY และ

ทุ เวีย เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้วก็ตามโจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้

การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 นั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าโจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกัน TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ 2 รูปลูกศรสลับหัวWAY อันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศร ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะแบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่ปรากฏว่าโจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น Tellme TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY POWDERCAKE หรือ Tellme Creance 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากคำเบิกความของนางพรรณวดี วิวัฒรางกูล ที่ประกอบอาชีพค้าขายที่ร้านชินกิมหลี พยานโจทก์ว่าตนทราบดีว่าแป้งทุเวียเพาเดอร์เค้กไม่ได้มีเฉพาะยี่ห้อของโจทก์เท่านั้นยังมียี่ห้ออื่นที่จำหน่ายอีก แต่แป้งของโจทก์หรือเทลมีขายได้ดีอันเป็นการแสดงว่าคำว่า TWO WAY เป็นเพียงการกล่าวถึงคุณสมบัติการใช้ของแป้งผัดหน้าเท่านั้น ส่วนจะเป็นแป้งผัดหน้ายี่ห้อใดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้จะพิจารณา ดังนั้นการที่นางสาวประกายคำใช้คำว่า "ทุเวียเคค" มิได้ใช้ TWO รูปลูกศรสลับหัว WAY หรือ 2 รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sun melon เป็นเครื่องหมายการค้าแม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันและจะถือว่านางสาวประกายคำมีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทุเวียเคค" ประกอบคำว่า ชันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าดังเช่นที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้อุทธรณ์ของโจทก์แล้วพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พินิจ เพชรรุ่ง-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-สบโชค สุขารมณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>